

1501900-69.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... cuja finalidade é o comércio. O tráfico de entorpecentes, como é cediço, é crime de ação múltipla, bastando, para sua caracterização, que a conduta do agente seja subsumida num dos verbos empregados pelo referido artigo.

"Tóxico. Tráfico. Caracterização. Para caracterização do delito do art. 12 da Lei 6.368/76, da modalidade de tráfico, não se exige prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Jardim das Flores, cep 06110-100, Osasco, SP

Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Processo Digital 1501900-69.2020.8.26.0542 | Sentença | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501900-69.2020.8.26.0542

Controle: 2020/001677

Autor:

Justiça Pública

Acusado:

ANDERSON SANTOS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

ANDERSON SANTOS SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, em 27 de agosto de 2020, por volta das 2h20min, na Rua Padre Josino Tavares, 24, Bonança, nesta Cidade e Comarca de Osasco/SP, trazia consigo: 81 invólucros plásticos contendo 178,20g de maconha, 81 invólucros plásticos contendo 26,41g de cocaína, e 76 invólucros plásticos contendo 15,83g de crack, todas substâncias entorpecentes, capazes de determinar a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, na data supra, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, ocasião em que avistaram Anderson caminhando pela via pública, segurando uma sacola plástica.

Ante a presença da polícia, Anderson tentou se evadir, mas foi abordado.

No interior da sacola estavam acondicionadas as porções de drogas. Com ele foi localizada a quantia de R\$ 21,00 em dinheiro.

A denúncia foi ofertada e notificado Anderson (fls. 99). Sobreveio a defesa preliminar (fls. 104/107) e, não havendo causas de sumária absolvição, a denúncia foi recebida em 6 de novembro de 2020 (fls. 109/111). Anderson foi citado (fls. 131).

Durante a instrução processual criminal foram ouvidas testemunhas (fls. 140/141) e interrogado o acusado (fls. 142).

Encerrada a instrutória, nada foi requerido, sendo os debates orais convertidos em memoriais escritos (fls. 143).

Em sede de memoriais escritos, o Dr. Promotor de Justiça pleiteou pela procedência da ação penal e consequente condenação de Anderson nos termos da denúncia (fls. 146/151).

A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pela aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (fls. 155/168).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

A materialidade delitiva consubstancia-se em auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 7/10), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 82/84), bem como pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório (fls. 140/141) e, especialmente, pela confissão judicial de autoria (fls. 142).

Perante a D. Autoridade Policial, Anderson afirmou que em 27 de agosto de 2020, por volta das 2h, estava no local do ocorrido, comercializando drogas, quando foi surpreendido por uma equipe da Polícia Militar. Com a aproximação dos milicianos, alguns usuários de drogas que ali se encontravam correram, enquanto pegou a sacola contendo as drogas e tentou se evadir, porém acabou sendo capturado ali. É usuário de maconha e resolveu comercializar drogas por empolgação. Um indivíduo menor de idade já deixou as drogas ali na sacola para que pudesse vender, sendo que a porção de maconha era vendida por R\$ 5,00, a de crack por R\$ 5,00 e a de cocaína por R\$ 10,00. Receberia R\$ 100,00 se consumasse a venda de drogas aquelas porções que trazia consigo. O aparelho telefone celular encontrado na sacola foi deixado pelo menor, caso precisassem se comunicar, mas não chegou a utilizar (fls. 5/6).

A confissão extrajudicial da autoria, como é cediço, vale não pelo lugar em que é prestada, mas pela força de convencimento que nela contém (RT 95/563). É mister emprestar-lhe a necessária credibilidade, vez que vem corroborada pelas demais provas amealhadas aos autos. Neste sentido:

“Em regra, a prova constante do inquérito policial não deve ser desprezada, mormente em caso em que o delito ocorre sob a clandestinidade, como o furto. As confissões nele obtidas regularmente estando seus termos em consonância com as demais circunstâncias dos autos, têm valor probante e podem ser aceitas, se não elididas na fase judicial” (TACRIM/SP - Acrim 22.508).

Em Juízo, novamente, confessou a prática delitiva. Afirmou que estava desempregado e precisando. Estava com uma sacola com drogas e foi abordado. Declarou seu arrependimento (fls. 142).

Inferi-se que a confissão representa idôneo liame entre a autoria e o evento perpetrado, encontrando-se corroborada pelas demais provas produzidas, inclusive pela confissão extrajudicial de autoria. Deve, pois, ser considerada sincera. Neste sentido:

“Confissão Judicial - Ausência de circunstância que evidenciem insinceridade - Suficiência - Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa”. (Ap. 470.903-2-SP - 8a C. - TACrim - j. 08.10.87 - Rel. Juiz Canguçu de Almeida).

Outrossim, não comprovado o alegado estado de necessidade, inviável é a aplicação do artigo 24, do Código Penal.

A testemunha Policial Militar Dário Antônio narrou que, em patrulhamento no local já conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistou o acusado com uma sacola nas mãos. Houve tentativa de abordagem, sendo que ele saiu em sentido contrário. O acusado foi abordado com a sacola em mãos. No interior da sacola havia porções de drogas, maconha, cocaína e crack, pequena quantidade de dinheiro e aparelho celular.

O abordado, ao avistar a viatura, tentou se evadir, acelerando o passo em sentido contrário da viatura e estava com volume na sacola que levava. Isso motivou a abordagem. O acusado estava andando e quando viu a viatura voltou em sentido contrário da viatura. Ele não tentou dispensar a sacola. Era uma sacola plástica. Foi seu parceiro que fez a revista na sacola. Não havia outras pessoas no local. Não havia outras pessoas passando na rua. O acusado informou que estava desempregado, exercia o tráfico de drogas e recebia R\$ 100,00 por dia. O acusado estava com cerca de vinte e poucos reais (fls. 140).

A testemunha Policial Militar Marcelo Henrique asseverou que, em patrulhamento na área já conhecida como ponto de tráfico de drogas, avistaram o acusado. Quando ele viu a viatura, ele acelerou o passo e tentou se evadir, mas foi abordado. Ele estava com sacola que continha quantidade de drogas. Posteriormente ele confessou a prática de tráfico dizendo que recebia aproximadamente R\$ 100,00 por noite.

Não se recordou a cor da sacola em razão do tempo decorrido. Era um tipo de sacola plástica, de mercado. O acusado já estava com a sacola, quando o avistaram e ele correu com ela, sendo abordado também com ela.

Foi o declarante quem fez a revista pessoal e havia dinheiro com ele. Em razão do tempo não se lembrou se havia outras pessoas próximas do acusado no momento da abordagem. Pelo que se recorda os fatos ocorreram na madrugada. O acusado chegou a mudar de direção e correr. Calcula que o acusado teria corrido por 50m. Ele continuou segurando a sacola. Correram atrás dele a pé. O acusado informou que estava desempregado e por isso na prática da venda de entorpecentes (fls. 141).

Os testemunhos policiais demonstram a veracidade dos fatos, até porque responderam às indagações formuladas, apresentando as mesmas circunstâncias, tanto no aspecto principal quanto no secundário, quer na fase extrajudicial como em Juízo.

Outrossim, corroboradas pela confissão extra- e judicial de Anderson.

É cediço que o testemunho policial não é afetado, positiva ou negativamente, pela função que exerce. A condição funcional não confere ao seu testemunho maior força persuasória e nem o inquina de suspeição. O valor probante de sua versão é aferido pelo mérito e de acordo com o grau de confiabilidade segundo a harmonia das provas coligidas aos autos. Neste sentido, vasta é a jurisprudência proclamada pela suficiência, se coesos os testemunhos policiais, para embasar o édito condenatório.

"PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhos, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido Os policiais militares como qualquer outra pessoa não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial" (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal n. 153.694-3 - São Paulo - 26.09.94).

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Droga apreendida nas mãos dos apelantes - Grande quantidade - Policiais que se infiltraram na quadrilha afim de se passarem por traficantes - Prova colhida que aliada ao depoimento dos policiais que autorizam a condenação - Recurso não provido. É inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (Apelação Criminal n. 157.320-3 - Limeira - 3ª Câmara Criminal - Relator: Irineu Pedrotti - 13.11.95 - V.U.).

As provas são uníssonas e coesas quanto à responsabilidade criminal de Anderson. Ele foi abordado em conhecido ponto de traficância, após tentar fuga, levando uma sacola em mãos. Na sacola estava o entorpecente e havia dinheiro. Informalmente, extrajudicialmente e em Juízo, Anderson confessou a prática delitiva.

Para caracterização do delito de tráfico ilícito de entorpecentes dever-se-á atender à natureza e a quantidade da substância entorpecente, ao local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Seguindo essas variantes houve plena demonstração do animus de traficar, sendo robusto o material cognitivo.

Ora, os elementos citados são suficientes e indicam que o material tóxico apreendido se destinava ao comércio ilícito.

Anderson foi denunciado por trazer consigo substância entorpecente cuja finalidade é o comércio. O tráfico de entorpecentes, como é cediço, é crime de ação múltipla, bastando, para sua caracterização, que a conduta do agente seja subsumida num dos verbos empregados pelo referido artigo.

"Tóxico. Tráfico. Caracterização. Para caracterização do delito do art. 12 da Lei 6.368/76, da modalidade de tráfico, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que os elementos indiciários, tais como a confissão extrajudicial, a quantidade do material apreendido, a conduta e os antecedentes dos agentes, bem como as circunstâncias da prisão, evidenciem a atividade delituosa" (TJRJ - ApCrim 5.492 in Direito Concreto, v. 5, p. 191).

"Desimporta se o agente não chegou a vender o tóxico, pois trazer consigo, já é delito consumado, segundo uma das normas múltiplas que contém o art. 12 da lei respectiva" (TJRS - AC 68.305.178-3 - Rel. Milton dos Santos Martins - RJTJRS 107/59).

Com esta prova a respeito da finalidade de entrega do entorpecente a consumo de terceiros não há que se cogitar da desclassificação para o delito preconizado no artigo 28, da Lei 11.343/06. Anote-se que a condição de eventual usuário não exclui a traficância. Vale ressaltar a quantidade de entorpecente que Anderson trazia consigo: 81 invólucros plásticos contendo 178,20g de maconha, 81 invólucros plásticos contendo 26,41g de cocaína, e 76 invólucros plásticos contendo 15,83g de crack.

Conclui-se, pois, pela procedência da ação penal e consequente condenação de Anderson Santos Silva por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Não agiu com intensidade dolosa incomum para os delitos da espécie a justificar a exacerbação da pena-base acima do mínimo legal, a teor do autorizado pelo artigo 59, do Código Penal.

Faz jus às atenuantes do artigo 65, incisos I e III, alínea d, do Código Penal, como é cediço, ao Magistrado não é dado transgredir os limites que a lei fixa para as penas, salvo nos casos em que tal faculdade é expressamente outorgada. Assim, inadmissível é a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, ainda quando se cuide de agente relativamente menor à época dos fatos e confesso extra- e judicialmente:

"Na aplicação da pena, as circunstâncias atenuantes, de consideração obrigatória, não permitem a fixação da reprimenda em parâmetros inferiores ao mínimo legal, não havendo confundi-las com as causas de diminuição de pena, que, estas sim, ensejam essa possibilidade". (RJD 23/299)

É de se observar que a Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça não revogou sua Súmula 231. As atenuantes do artigo 65, incisos I e III, alínea d, do Código Penal continuam não tendo o condão de reduzir a reprimenda para abaixo do mínimo legal.

Neste sentido, inclusive, já decidiu o próprio Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. SÚMULA 545/STJ. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE SEM REFLEXOS NA PENA. SÚMULA 231/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - De acordo com o enunciado n. 545/STJ, "Quando a confissão for utilizada para formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal". III - In casu, a forma da confissão da paciente, para se beneficiar de tese da defesa, configura confissão qualificada, de modo que foi expressamente confirmado pelo juiz de origem que a paciente admitiu a imputação dos fatos relativos ao dia 06/01/2016. IV - Destarte, considerando a utilização da confissão para formara convicção do julgador, deve ela ser apreciada como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. Entretanto, considerando que a pena-base da paciente foi fixada no mínimo legal,

"[n]os termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (AgRg no AREsp n. 623.682/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/10/2015). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão na dosimetria, sem reflexos na pena definitiva (Súmula 231 STJ), mantidos os demais termos da condenação" (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 431.336-RS. Relator: Ministro Felix Fischer. Julgamento: 12 de junho, 2018. Publicação: 15 de julho, 2018).

É primário e não ostenta maus-antecedentes criminais.

É pertinente a redução prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.887.511-SP, que fixou diretrizes acerca da consideração da quantidade e variedade de entorpecentes na dosimetria da pena.

"PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira. 4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos – necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas – para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria. 5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual. 6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual. 7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712). 8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa. 9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena base. 10. Recurso provido para restabelecimento da sentença" (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em

09/06/2021, DJe 01/07/2021).

Assim, tratando-se de agente primário, a redução deve se dar em seu grau máximo, ou seja, 2/3, conforme o preconizado pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Considerando os parâmetros acima e os demais critérios preconizados pelo artigo 59, do Código Penal, fixo, a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados na base. Deixo de atenuar a reprimenda pela incidência do artigo 65, incisos I e III, alínea d, do Código Penal, por já estar em seu patamar mínimo para esta fase da dosimetria, não podendo ficar aquém disso, conforme o assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula 231. Não há outras atenuantes ou agravantes. Reconhecida a aplicação do § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, resultando em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, calculados na base. Não há outras causas de diminuição ou de aumento.

À mingua de outras causas legais de alteração torno esta pena definitiva.

Em face do disposto no artigo 33, alínea c, do Código Penal e artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, fixo o regime inicial aberto. Por força da Resolução 5/2012 do Senado Federal, não havendo óbice, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no importe de um salário-mínimo nacional à A.A.C.D./Osasco-SP e prestação de serviços à comunidade, por igual prazo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO ANDERSON SANTOS SILVA, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial aberto, a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime, substituindo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no importe de um salário-mínimo nacional à A.A.C.D./Osasco-SP e prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nos termos do artigo 60, c.c. o artigo 63, caput, da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 125, do Código Penal, atendido ao requisito do artigo 126, do Código Penal, e a teor do artigo 127, do Código Penal, decreto o perdimento do numerário apreendido, dada sua origem ilícita.

No mais, autorizo a destruição do entorpecente nos termos regimentais, bem como do aparelho telefone celular.

Por derradeiro, defiro as benesses da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98, § 1º, incisos I ao IX, do Código de Processo Civil, c.c. o artigo 1º, da Lei 1.060/50, com observância da ressalva do artigo 98, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

P. I.C.

Osasco, 23 de março de 2022.